

1508412-06.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092332/2021 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 17161086 - 20º D.P. AGUA FRIA, 1380/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2092332 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508412-06.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508412-06.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092332/2021 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 17161086 - 20º D.P. AGUA FRIA, 1380/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2092332 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELE CAROLINE FANELI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

DANIELE CAROLINE FANELI DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 78-79), no dia 05 de abril de 2021, por volta das 12 horas e 20 minutos, no interior da Penitenciária Feminina de Santana, localizada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 656, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo, guardava, mantinha em depósito, trazia consigo, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 46 porções de "K4", droga sintética derivada da maconha (ADB-Butinaca), com peso líquido de 0,04g, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a inicial, a acusada era detenta, custodiada no estabelecimento prisional acima indicado. Na ocasião dos fatos, agentes penitenciários que realizavam ronda na parte interna do 3º Pavilhão, avistaram DANIELE apanhar um objeto que foi jogado do pátio do 2º Pavilhão para o 3º Pavilhão. Porém, ao notar a aproximação dos agentes, a acusada arremessou o pacote para o interior da cela 1036. Prontamente, os agentes foram até a referida cela, que estava desativada, e recuperaram o pacote anteriormente dispensado. Em vistoria, no interior do pacote, os agentes encontraram a droga acima descrita.

Ao que consta da denúncia, este volume teria alto valor econômico no interior da unidade prisional, sendo que a acusada, naquele momento, disse que ficaria com dois micropontos da droga para consumo próprio e o restante seria entregue a outra detenta.

Presa em flagrante delito, foi realizada análise judicial de regularidade formal da prisão, que foi devidamente homologada e convertida em prisão preventiva, às fls. 55-58.

Às fls. 87-89, foi juntado o Laudo de Exame Químico-Toxicológico definitivo nº 115.213/2021, a atestar a quantidade de 0,04 gramas da substância ADB-BUTINACA. Regularmente notificada, foi oferecida defesa preliminar, às fls. 110-111, pela Defensoria Pública.

Foi realizada instrução processual, que se encerrou (fls. 139-142), seguida da sentença de mérito, condenatória, de fls. 143-150.

Entretanto, Defensor Constituído pela acusada opôs recurso de apelação ao qual foi dado provimento, para anular o feito, desde o oferecimento da defesa preliminar, pois ao ser notificada da denúncia, a acusada afirmou contar com advogado constituído, indicando seu nome, mas não houve intimação do defensor, tendo a Defensoria Pública atuado.

No r. voto, foi assinalado estar evidenciado o prejuízo, sobretudo diante do fato de que o advogado constituído acompanhou todo o Procedimento Administrativo Disciplinar no âmbito da administração penitenciária, bem como seu desenvolvimento perante o Juízo das Execuções Criminais.

Retomado o andamento do feito, a defesa constituída apresentou defesa (fls. 263).

À fls. 291, a defesa juntou documentos.

Durante a instrução processual, foram colhidos os relatos das testemunhas agentes penitenciários Samuel Alves de Moraes e Sharlene de Oliveira Santos. A acusada foi interrogada, declarando-se encerrada a instrução processual.

As partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público, em suma, postulou a condenação da acusada, nos termos da denúncia, por reputar comprovada a materialidade e autoria delitiva. Com relação à fixação da pena, assinala tratar-se de reincidente, com maus antecedentes, não sendo ainda aplicável o fator redutor da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pede o reconhecimento da causa de aumento da pena da prática do delito no interior de estabelecimento prisional. Postula a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição da acusada, diante da fragilidade das provas de acusação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ressalta que os depoimentos prestados em audiência pelas duas testemunhas agentes penitenciários divergem daqueles que prestaram anteriormente,

no procedimento administrativo disciplinar. Subsidiariamente, requereu: a) o reconhecimento de que o crime ficou na modalidade tentada, pois os agentes penitenciários estavam cientes de que o fato ocorreria, estando apenas no aguardo de sua ocorrência, prontos para deter a acusada; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois a acusada prestou auxílio lateral, de menor relevância. Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da cuidadosa análise do processado, a despeito da consistente manifestação final do Eminentíssimo Defensor da acusada, tenho por certo que a acusação inicial procede. Registro, inicialmente, imensa e permanente admiração deste magistrado ao grande profissional que, inequivocamente, marcou época e fez história no Ministério Público de São Paulo e enriquece a advocacia criminal, agora, como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, realizando notável defesa nestes autos processuais. A materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 5-7), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 8), do Laudo de Constatação (fls. 16-18), do Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87-89), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, está comprovada nos autos, sobretudo diante da prova oral produzida no curso da instrução processual.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha agente penitenciário Samuel Alves de Moraes narrou, em suma, que no dia dos fatos, durante ronda que fazia no pátio, presenciou a acusada pegando material arremessado de outro pavilhão, de outro pátio. Viu ela pegar um pacote. Assim que ela pegou o pacote, o depoente foi até ela indagando sobre o que era aquilo. A acusada arremessou o pacote para o interior de uma cela e disse que não era nada. O depoente foi até a cela e recuperou o pacote, abrindo-o. Ao abrir, verificou que se tratava de porções de K4. Ao que sabe, o K4 é um derivado da maconha, uma droga sintética, mais forte que a maconha, potencializada. Havia 46 micropontos de K4. Essas porções estavam dentro desse pacote. Quando identificou que se tratava de entorpecente, o depoente indagou para a acusada sobre o que seria feito daquilo e de quem era. Nesse momento, DANIELE assumiu que era dela e que seria para uso próprio. Disse que dois pontos seriam para uso próprio e o restante seria entregue para outra reeducanda. A acusada já estava aguardando o arremesso desse pacote de outro pavilhão. Quando saiu para a ronda, já tinha recebido a informação de que seria feito esse arremesso, pois pouco antes ouviu detentas combinando esta conduta. Essa droga tem valor muito significativo no interior do sistema prisional. Cada microponto é comercializado no valor equivalente a algo entre quatro e seis maços de cigarro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha agente penitenciária Sharlene de Oliveira Santos, que relatou, em síntese, que no dia dos fatos, no pavilhão três, estava em ronda com o agente Samuel. Olhou pela janela que dá acesso ao pátio de sol, no instante em que um pacote foi arremessado do segundo pavilhão para o terceiro e viram DANIELE pegar esse pacote. Imediatamente ingressaram no pátio. Só que a acusada jogou o pacote para o interior de uma cela desativada. Indagada, ela disse que não era nada. Ingressaram na cela e localizaram o pacote, contendo 46 micropontos de K4. Esses micropontos tem por princípio ativo a cannabis. É um derivado da maconha, mas ao que sabe, mais forte. O valor disso no interior do sistema penitenciário é bem alto. Troca-se por maços de cigarros e o valor é expressivo. Indagada sobre a droga, a acusada chorava e dizia que um pouco era dela, mas que o restante seguiria para outra pessoa, seria entregue a outra detenta. Ao que perceberam, a acusada já estava no aguardo do arremesso desse pacote. Estava posicionada no terceiro pavilhão esperando que arremessassem o pacote. DANIELE relatou isso à depoente, dizendo, inclusive, que uma acompanhante de cela dela pediu a ela que não descesse para pegar a droga, que não fizesse isso. Durante a ronda, escutaram detentas falando que fariam isso, esse arremesso da droga. Elas não viram os agentes, mas eles ouviram, inclusive para ouvir quem pegaria a droga. Estavam em ronda, quando houve o arremesso, já atentos por saberem

que isso ocorreria. Ficaram no local esperando o momento do arremesso da droga. Ao ser interrogada em juízo a acusada negou a prática delitiva, negando ciência de que havia droga no pacote que pegou. Em síntese, narrou que sempre trabalhou enquanto esteve presa na Penitenciária Feminina de Santana. Ficou um ano e meio em Santana e sempre trabalhou em uma metalúrgica. Morava na cela com sua companheira. Nesse dia, depois do almoço, teve uma discussão e desceu para o pátio. No pátio, encontrou uma detenta conhecida por Juninho. Ela pediu à acusada que pegasse um pacote que seria jogado do pavilhão 2. Ela pegaria o pacote e entregaria para Juninho. Não sabia que se tratava de drogas. Não é dada a esse tipo de crime, nunca traficou drogas. Era usuária de drogas quando estava nas ruas, mas desde que foi presa parou de usar drogas, tanto que sempre trabalhou no sistema prisional. Não usava drogas dentro do presídio e não traficava.

Pois bem, a despeito da negativa de ciência de que o embrulho que foi arremessado do pavilhão vizinho para o pátio do pavilhão em que estava, e que, na ocasião recolheu, continha drogas, esta versão além de não se revelar como verossímil, não conta com nenhum respaldo em outras provas dos autos, sendo que, ao contrário disto, há provas de que tinha sim ciência de que se cuidava de drogas.

Ainda, está bem comprovado nos autos de que recebeu aquela droga para repassar a terceira pessoa, em contexto próprio de traficância no interior de unidade prisional na qual estava reclusa.

Os agentes penitenciários, ao serem ouvidos em juízo, nesta última audiência, foram claros e precisos ao afirmar que a acusada, logo que pegou o pacote e que os agentes dela se aproximaram, prontamente arremessou o embrulho para o interior de uma cela que estava desocupada e, logo após, quando os agentes pegaram o embrulho, reconheceu que ficaria com dois dos quarenta e seis pontos de droga e que entregaria o restante para uma outra detenta.

É certo que a defesa juntou relatório elaborado pelos agentes penitenciários que figuram como testemunhas nestes autos (Samuel e Sharlene), à fls. 295-296, constante do procedimento administrativo da Administração Penitenciária, a fim de apurar falta disciplinar da acusada, no qual não consta nenhuma menção ao fato de a acusada ter admitido ciência de que se tratava de entorpecentes e que ficaria com dois micropontos, repassando o restante para terceira pessoa.

Contudo, há que se ponderar que se trata de relatório sintético, elaborado no momento dos fatos, sendo certo que, na ocasião do ocorrido, na lavratura da ocorrência perante a Autoridade Policial, no mesmo dia dos fatos, comunicaram tal fato, da admissão da ciência de que se cuidava de droga a ser repassada a terceira pessoa e que a acusada ficaria com pequena parcela para si.

E em juízo, ambos os agentes penitenciários confirmaram tal contexto, não sendo possível afastar a certeza de que DANIELE aguardava o embrulho que seria arremessado, a fim de pegá-lo, sabendo tratar-se de entorpecente, certo ainda de que pretendia pegar para si dois micropontos de um total de quarenta e seis e que repassaria o restante para outra detenta.

Com isto, fica bem revelada a perspectiva da traficância, na modalidade da guarda, manutenção e de trazer consigo o entorpecente, destinado ao consumo de terceiros, ainda que de forma gratuita.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos agentes penitenciários foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos agentes da Administração Penitenciária militares quanto à apreensão das substâncias entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar a acusada, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Observo, ainda, que a partir do instante em que a acusada recebeu a droga, ainda que por breve instante, mantendo sob sua posse, prontamente o delito se consumou, não havendo que se falar em tentativa. Tão logo realizada a conduta, no instante em que iniciado o ato de execução, já se tem por consumado o delito, de forma que, no instante em que a acusada recebeu a droga, que, diga-se, já estava programada para lhe ser entregue, consumou-se o ato de guarda e de trazer consigo o entorpecente.

Como acima assinalado, a finalidade de narcotraficância ficou bem evidenciada, observado o contexto em que praticada a conduta e a destinação, ainda que graciosa, a terceira pessoa. Aqui, ao que consta, a acusada ficaria com uma pequena porcentagem, de dois micropontos de K4, de um total de quarenta e seis micropontos, e repassaria quarenta e quatro para outra detenta.

Desta forma, evidencia-se que todos os elementos de prova convergem para a demonstração certa da prática do delito de tráfico de drogas, na forma consumada, impondo-se a condenação da acusada nos termos da denúncia.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006.

O inciso III, do artigo 40, da Lei de drogas estabelece que a pena suportará aumento de um sexto a dois terços se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. O caso vertente ocorreu no interior de estabelecimento prisional, realizado precisamente em razão desta situação própria da acusada, da pessoa que lhe repassou a droga e daquela a quem entregaria.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena, atento ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, a partir da certidão de fls. 27-31, colhe-se que a acusada, ao tempo dos fatos, registrava três condenações já transitadas em julgado. Uma delas afirma sua reincidência, o que será aferido na segunda fase de fixação. As outras duas, colhendo-se aqui aquela dos autos do processo nº 0005603-66.2012.8.26.0541, que tramitou perante a 3ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul / SP, bem como a dos autos do processo nº 0002606-13.2012.8.26.0541, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul / SP, para atestar seus antecedentes negativos. Em razão disto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (em razão da condenação transitada em julgado no dia 31/3/2015, nos autos do processo nº 0003160-74.2014.8.26.0541, da 3ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul / SP), culminando com a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena de 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Cada dia-multa fica fixado no valor mínimo legal, porquanto ausente qualquer indicativo de potencial de custeio de valor superior a este. Ao revés, tudo está a demonstrar que a acusada não conta com recursos financeiros para satisfazer penalidade em patamar mais elevado.

Insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, observada a reincidência da acusada.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que a acusada é reincidente, além de ostentar maus antecedentes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural da presente ação penal, a fim de CONDENAR a acusada DANIELE CAROLINE FANELI DA SILVA, qualificada nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 793 (setecentos e

noventa e três) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. Considerando que a acusada vem respondendo aos termos da demanda presa cautelarmente, não havendo nada que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade, fica mantida a sua custódia cautelar, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se a acusada no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno a acusada a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando expressamente deferido, neste ato, o benefício da gratuidade da justiça. Anote-se.

Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis.

Em havendo recurso, fica desde já determinada a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA